

1500267-93.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... o que revela a sua participação no tráfico praticado por Adão.

Assim, ao revés do que alega a defesa, há mensagens indicativas de tráfico e da participação de Lilian no comércio espúrio e que, portanto, afastam as justificativas apresentadas pelos acusados.

No mais, o fato de os réus não terem sido surpreendidos no exato momento da comercialização do entorpecente não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500267-93.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2050151/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23161312 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1019/22/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2050151 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LILIAN RENATA GABRIEL e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

ADÃO ANDRÉ BENTO e LILIAN RENATA GABRIEL estão sendo processados como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificados às fls. 387 (Adão) e 391 (Lilian), os réus apresentaram resposta às fls. 401/403 (Adão) e fls. 404/406 (Lilian).

A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2022 (fls. 407/408) e os réus foram citados às fls. 442 (Lilian) e 448 (Adão).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e os réus foram interrogados

(fls. 456).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 456).

A defesa postulou a desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei 11.343/06 ou, subsidiariamente, a aplicação do parágrafo 3º, do artigo 33, do mesmo diploma legal (fls. 456).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 6/9), boletim de ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), fotografias (fls. 73/78), laudos periciais (fls. 218/226 e 227/232), informação (fls. 234/253), além da prova oral.

A autoria também é certa.

Em juízo, Lilian rechaçou a acusação. Disse que não tinha ido trabalhar no dia dos fatos, pois estava realizando sua mudança. Negou ser usuária de drogas e afirmou que os pinos de cocaína que estavam em sua cama lhe haviam sido dados por Adão na noite anterior, pois ele estava transtornado. Afirmou que já teve um relacionamento amoroso com Adão e negou que tivesse movimento típico de comércio espúrio na casa onde moravam. A residência da parte superior é independente da parte inferior.

O réu Adão negou os fatos. Alegou que é dependente químico e que as drogas apreendidas eram para seu uso. Negou ter dito aos policiais que era membro de facção criminosa e afirmou que estava realizando serviços eventuais como servente de pedreiro, pelo qual percebia cerca de R\$90,00 ao dia. Durante a diligência de busca e apreensão, estava alucinado pelo uso de drogas e apontou aos policiais onde estavam os entorpecentes. Havia dado a Lilian as cápsulas de droga encontradas no colchão dela. O dinheiro que portava era proveniente de trabalho lícito. Aduziu que está sendo perseguido pelos policiais, a quem não conhecia anteriormente, por conta de seu passado no crime. Nada sabe acerca das anotações apreendidas e acredita que pertençam a antigos moradores do imóvel. Negou a existência de conversas em seu celular referente ao tráfico de drogas. Alegou que, no diálogo com "Anne", sua conhecida do bar, apenas tratou sobre valores que um terceiro devia a ela, por conta de um acidente automobilístico. Lilian também conversou com "Anne" pelo seu celular. Na data dos fatos, havia mais duas amigas em sua casa fumando crack, que havia comprado para o uso comum.

O policial civil Paulo relatou ter tomado conhecimento de denúncias de que dois homens praticavam o tráfico no local dos fatos, o que motivou a expedição de mandado de busca e apreensão. Dias antes do cumprimento da diligência, aportaram informações de que o comércio espúrio seria praticado por um casal. Durante o cumprimento da diligência, a ré abriu o portão para a entrada da equipe e observou que ela morava na parte inferior da residência, enquanto o acusado ocupava a parte de cima do imóvel. Durante revista, encontrou porções brutas de crack na cueca do réu e, em seus bolsos, porções fracionadas da mesma droga, além de alguns eppendorfs de cocaína e dinheiro. Adão alegou que a droga seria destinada ao próprio uso e que integrava o Primeiro Comando da Capital. No quarto da ré havia mais dois pinos de cocaína idênticos aos que estavam com Adão, que ela afirmou se destinarem ao próprio uso, além de R\$50,00.

Bruno, policial civil, confirmou a narrativa de seu colega e acrescentou que o celular do réu Adão foi apreendido e, durante vistoria no aparelho, encontrou

diálogos que denotavam que ambos os acusados praticavam o tráfico de drogas em associação. No decorrer da diligência algumas pessoas chegaram ao local, mas não foram conduzidas à delegacia, pois não portavam nada de ilícito.

Maria Eduarda, filha da ré, narrou que estava presente na residência no momento da diligência, porque residia na parte de baixo do imóvel com sua mãe, que trabalha com calçados. Negou que ela comercializasse entorpecentes.

A testemunha Márcia contou que a ré trabalhou em sua banca de calçados e atualmente labora em uma fábrica de calçados. Teceu bons comentários acerca da conduta da acusada e negou que ela comercializasse entorpecentes.

A despeito da negativa dos réus, as provas são suficientes para condenação.

Cumpra, desde logo, observar que inexiste vedação legal ou constitucional à notícia anônima de crime. Como bem se sabe, o Poder Público incentiva a população a que informe às autoridades os fatos criminosos de que tenham conhecimento, visando, assim, dar mais efetividade à prevenção e à repressão de delitos.

Nessas situações, a pessoa não é compelida a se identificar, o que estimula a participação da comunidade no combate à criminalidade. Portanto, seria um contrassenso estimular a sociedade a denunciar uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subsequentes, ainda que produzidas lícitamente a partir daquela.

E, por óbvio, não foram as referidas denúncias que acarretaram a prisão dos réus, mas o encontro das drogas, das mensagens de celular e das anotações contábeis (fls. 19/20), tudo a corroborar as informações recebidas pelos policiais.

Ainda neste norte, nada se alegou capaz de afastar a credibilidade dos relatos apresentados pelos policiais civis, que, no mais, revelaram-se coerentes e harmônicos com o restante da prova.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Na primeira vez em que foi ouvida, a ré alegou que a droga que estava em sua cama seria para o uso próprio (fls. 13/14) e, sob o crivo do contraditório, mencionou que não mais usava drogas e havia "esquecido" os pinos que Adão lhe havia dado na

noite anterior.

Além do encontro de drogas na casa dos acusados e de dinheiro sem comprovação de origem lícita, as mensagens extraídas do celular do réu (contidas na informação de fls. 234/253) denotam que ele praticava o tráfico, com a participação da ré.

Na pg. 236, Adão envia ao interlocutor "Pia" uma fotografia de uma porção de crack em uma balança e faz combinações para que alguém compareça em sua casa.

Na conversa de fl. 238, ele menciona a compra de 1Kg "da lata do óleo" (gíria indicativa de crack) e trava conversas com a interlocutora Anne acerca do recebimento de dívidas de drogas, embora tentando disfarçar a natureza da transação.

Nesse ponto, cumpre destacar que Lilian também conversa com Anne pelo celular de Adão (fato confirmado por ele) e, no diálogo constante nas fls. 249/250, afirma que irá acompanhá-lo na cobrança de R\$ 400,00 do indivíduo que tinha chamado "o irmão de mentiroso", o que revela a sua participação no tráfico praticado por Adão.

Assim, ao revés do que alega a defesa, há mensagens indicativas de tráfico e da participação de Lilian no comércio espúrio e que, portanto, afastam as justificativas apresentadas pelos acusados.

No mais, o fato de os réus não terem sido surpreendidos no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que, como cediço, elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal.

Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor dos acusados, que não trouxeram elementos a infirmá-lo. E, ainda que eles também sejam usuários, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem.

Sobre o tema, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Assim, a condenação é medida que se impõe.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Adão André Bento

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva de parte do entorpecente apreendido ("crack"), substância altamente nociva e viciante. Verifico, outrossim, que o acusado ostenta maus antecedentes (Proc. nº 0012145-61.2000.8.26.0302 - fls. 365/366, 0012149-98.2000.8.26.0302 - fls. 366/367, 0012220-37.1999.8.26.0302 - fls. 367, 0014884-65.2004.8.26.0302 - fls. 368 e 0002844-84.2000.8.26.0498 - fls. 372), pelo que fixo sua pena-base acima do mínimo legal em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do

Governo do Estado de São Paulo – ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: “Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”), além da reincidência (por duas condenações), que é, inclusive, específica (fls. 363/364 – Proc. 0000026-28.2015.8.26.0598 e fls. 372 – Proc. 0000250-76.2016.8.26.0453). Assim, majoro a reprimenda para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência do réu e os seus maus antecedentes ensejam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Assim, a reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a reincidência, os maus antecedentes e os motivos esposados na primeira fase, a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, CP.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI,

da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim, por entender que o art. 387, §2º, CPP viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Lilian Renata Gabriel

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva de parte do entorpecente apreendido ("crack"), substância altamente nociva e viciante. Verifico, outrossim, que a acusada ostenta maus antecedentes (Proc. nº 0017990-98.2005.8.26.0302 – fls. 360/361), pelo que fixo sua pena-base acima do mínimo

legal em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo – ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"), além da reincidência, que é, inclusive, específica (fls. 359 – Proc. 0007342-76.2016.8.26.0598). Assim, majoro a reprimenda para 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência da ré e os seus maus antecedentes ensejam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Assim, a reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a reincidência, os maus antecedentes e os motivos esposados na primeira fase, a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, CP, o réu ADÃO ANDRÉ BENTO à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 888 dias-multa, no mínimo legal, e LILIAN RENATA GABRIEL à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, no mínimo legal.

O acusado Adão respondeu ao processo preso e agora, com maior razão, não poderá apelar em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente a necessidade de impedir a reiteração criminosa. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra. Lilian poderá apelar em liberdade, pois assim permaneceu no curso do processo.

Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do dinheiro e do objeto apreendidos. Custas na forma da lei. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA